Aktenzeichen:
7 O 29/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

gegen

- Beklagte -

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - ... auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 04.11.2016 für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben a und b unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 12. September 2009

Multiplexgeräte zum Multiplexen von Datenpaketen mit verschiedenen zugeordneten Prioritäten, mit: Mitteln zum Empfangen von Datenpaketen; Mitteln zum Bedienen eines Warteschlangenspeichers für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen; Mitteln zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete, wobei durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher nach einer ersten Regel ein erster Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher

nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird; Mitteln zum Übertragen der Gruppe,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wenn das Multiplexgerät weiterhin Mittel umfasst zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher erfahrenen Verzögerung,

– Patentanspruch 7 –

und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I bezeichneten und seit dem 12. September 2009 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3, die Beklagte 1/3.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 50.000 in Ziffer I. und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages (Ziffer IV. Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des Patents EP 1 815 647 B1 auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

Die Klägerin ist ein weltweit operierendes Elektronikunternehmen, das u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie zahlreiche Patente hält. Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des taiwanesischen Unternehmens Z1 Corporation. Sie vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland UMTS- und LTE-fähige Mobiltelefone und Tablets unter der Marke „Z" (vgl. etwa Anlage K3a und b; im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen).

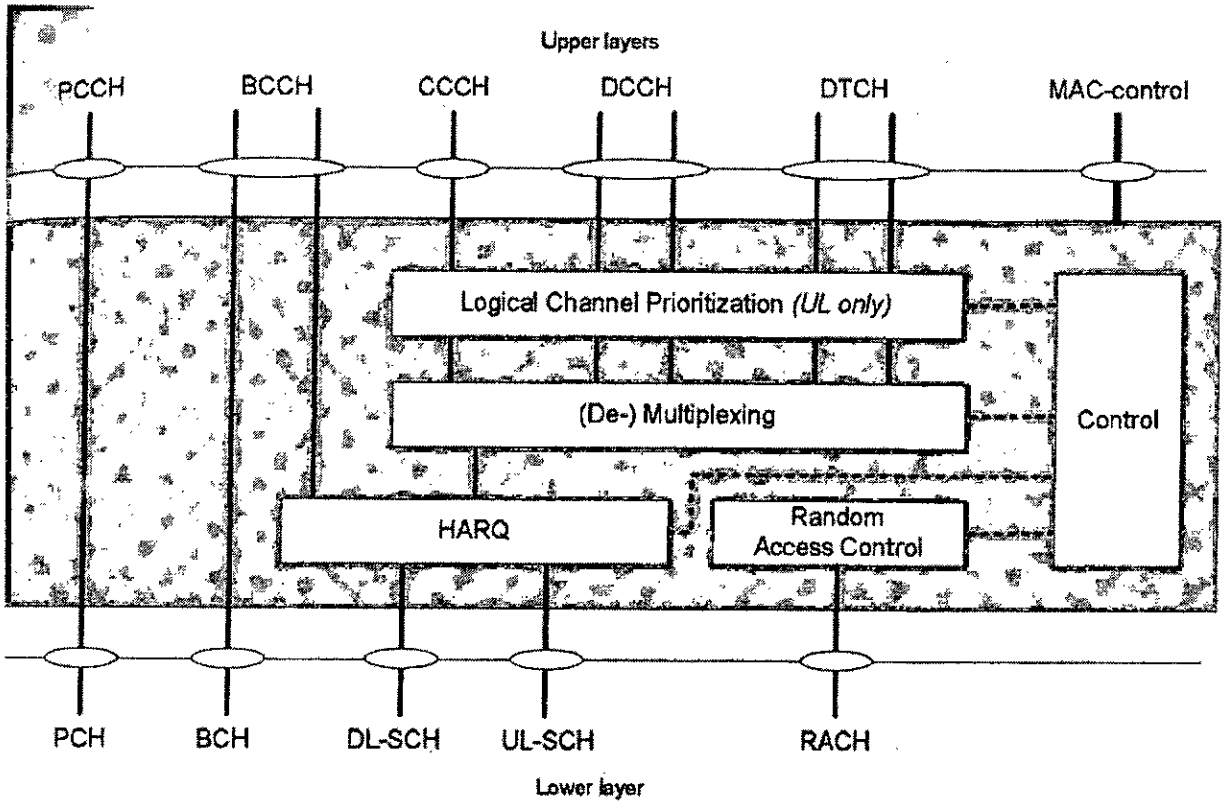
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Patents EP 1 815 647 B1, welches ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Zusammensetzen von Datenpaketen zum Gegenstand hat. Die Erteilung des am 04. November 2005 angemeldeten Patents wurde am 12. August 2009 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents (im Folgenden „Klagepatent") steht unter DE 60 2005 016 008.6 in Kraft. Der unabhängige Anspruch 7 des Klagepatents hat – in der Verfahrenssprache – folgenden Wortlaut:

> Multiplexing apparatus (300) for multiplexing data packets having different assigned priorities, comprising:
>
> means (30, 40) for operating a queue store (50) for each different priority of data packet;
>
> means (60, 80) for assembling a group of the data packets wherein a first portion (90) of the group is populated with data packets by selecting data packets from one or more of the queue stores (50) according to a first rule and a second portion (95) of the group is populated with data packets by selecting data packets from one or more of the queue stores (50) according to a second rule;
>
> means (100) for transmitting the group; and characterized by
>
> means (110) for adapting the size of the first and second portions (90, 95) according to the delay experienced by data in each queue store (50) relative to a delay criterion tor the respective queue store (50).

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Im Mobilfunkbereich gibt es verschiedene Standards, die die Anforderungen niederlegen, die u.a. Mobilstationen erfüllen müssen, um über den jeweiligen Standard am Mobilfunkverkehr

teilnehmen zu können. Die Anforderungen des sog. LTE(Long Term Evolution)-Mobilfunkstandards sind u.a. in dem Standard-Dokument 3GPP TS 36.321 V8.5.0 (2009-3) enthalten (im Folgenden kurz „Standard"). In dem Standard ist das Protokoll der sog. MAC (Medium Access Control)-Protokollschicht beschrieben, das von den Mobilstationen für die Nutzung der Luftschnittstelle des LTE-Standards, des sog. E-UTRA, befolgt werden muss. Auf der MAC-Ebene werden sog. Transportkanäle für die spätere Übertragung von Daten über die sog. physikalische Schicht verwaltet. Die MAC-Schicht ist – wie sich aus Abschnitt 4.4 des Standards ergibt – dazu in der Lage, durch Multiplexing MAC-Datenpakete (sog. MAC-SDUs), die ihr aus einem oder mehreren logischen Kanälen zugeführt werden, in Transportblöcken für die weitere Übersendung der Daten an die physikalische Schicht über die Transportkanäle zusammenzustellen. Die Zusammenhänge zwischen MAC-Schicht, den logischen Kanälen, den Transportkanälen und den weitergereichten Datenpaketen mit ihrer Zusammenstellung in Transportblöcke für die Weiterleitung über die Transportkanäle zeigt schematisch die nachstehend eingeblendete Figur 4.2.1.1 aus dem Standard:



In der eingeblendeten Figur sind die logischen Kanäle in dem mit „*Upper Layers*" überschriebenen Bereich und die Transportkanäle in dem mit „*Lower Layer*" gekennzeichneten Bereich schematisch erfasst, während die MAC-Schicht zwischen diesen beiden Bereichen liegt. Einer der Transportkanäle ist der sog. gemeinsam genutzte Uplink-Kanal UL-SCH (Uplink Shared Channel).

Nach Abschnitt 4.4 des Standards hat die MAC-Schicht auch die Funktion, unterschiedliche Priorisierungen zwischen unterschiedlichen logischen Kanälen einer Mobilstation zu handhaben. Das Verfahren für die logische Kanalpriorisierung beim Transportkanal UL-SCH ist in Abschnitt 5.4.3.1 des Standards niedergelegt, der im Folgenden auszugsweise wiedergegeben wird:

The Logical Channel Prioritization procedure is applied when a new transmission is performed.

RRC controls the scheduling of uplink data by signalling for each logical channel: *priority* where an increasing *priority* value indicates a lower priority level, *prioritisedBitRate* which sets the Prioritized Bit Rate (PBR), *bucketSizeDuration* which sets the Bucket Size Duration (BSD).

The UE shall maintain a variable Bj for each logical channel j. Bj shall be initialized to zero when the related logical channel is established, and incremented by the product PBR × TTI duration for each TTI, where PBR is Prioritized Bit Rate of logical channel j. However, the value of Bj can never exceed the bucket size and if the value of Bj is larger than the bucket size of logical channel j, it shall be set to the bucket size. The bucket size of a logical channel is equal to PBR × BSD, where PBR and BSD are configured by upper layers.

The UE shall perform the following Logical Channel Prioritization procedure when a new transmission is performed:

- The UE shall allocate resources to the logical channels in the following steps:
  - Step 1: All the logical channels with Bj > 0 are allocated resources in a decreasing priority order. If the PBR of a radio bearer is set to "infinity", the UE shall allocate resources for all the data that is available for transmission on the radio bearer before meeting the PBR of the lower priority radio bearer(s);
  - Step 2: the UE shall decrement Bj by the total size of MAC SDUs served to logical channel j in Step 1

NOTE: The value of Bj can be negative.

  - Step 3: if any resources remain, all the logical channels are served in a strict decreasing priority order (regardless of the value of Bj) until either the data for that logical channel or the UL grant is exhausted, whichever comes first. Logical channels configured with equal priority should be served equally.

Der Parameter B_j, der jedem der logischen Kanäle j zugeordnet und in der vorstehenden Einblendung erläutert ist, wird in jedem Übertragungszeitintervall (*Transmission Time Interval TTI*) für den betreffenden Kanal nach der Formel PBR x TTI erhöht und nach der Datenübertragung nach Schritt 1 in einem zweiten Schritt um die Gesamtgröße der nach obigem Schritt 1 zur Übertragung gelangten Daten aus dem betreffenden Kanal j verringert, wobei der Parameter B_j als Höchstwert höchstens die Übertragungsgrößeneinheit (bucket size) des betreffenden logischen Kanals j annehmen kann. Die Erhöhung wird dabei auch dann durchgeführt, wenn in dem logischen Kanal j keine Daten zur Übertragung anstehen.

Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent zum Bundespatentgericht erhoben (Anlagen(konvolut) TW4/WW1 bis WW6).

Die Klägerin wies die Muttergesellschaft der Beklagten schriftlich im November 2013 unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb ihrer Mobiltelefone UMTS- und LTE- standardessentielle Patente der Klägerin verletze. Zwischen März 2014 und Juni 2015 kam es zu sieben Treffen zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, in denen die Klägerin diese aufforderte, für USD ... pro verkaufter Einheit für den „past use" bzw. ... USD pro verkaufter Einheit in der „compliant rate" für die Zukunft Lizenz zu nehmen. Die Klägerin verwies auf L1, L2, L3, L4 und L5 als weitere Lizenznehmer, ohne deren Vertragskonditionen zu offenbaren, und verglich ihr eigenes Portfolio sowie die Lizenzrate mit der Rate, die von L6 gefordert wird. Mit Email vom 21. September 2015 übersendete die Klägerin an die Muttergesellschaft der Beklagten ein Lizenzvertragsangebot mit entsprechenden Konditionen sowie insgesamt 130 Claim-charts, hierunter mit der No. LTE#13 auch ein Claim-chart betreffend das Klagepatent. Am 20. November 2015 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, in denen die Parteien über die kaufmännischen Fragen einer Lizenz verhandelten, in dessen Zuge die Klägerin auf ein im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Sony eingeholtes Sachverständigengutachten, das USD ... pro Patent als Lizenz vorsehen soll, verwies, das der Beklagten indes nicht zugänglich gemacht wurde. Die Beklagte unterbreitete im Namen der Z1 Corporation ein Gegenangebot in der Klageerwiderung, das eine Lizenzgebühr von USD ... bezogen auf 89 in Kraft stehenden Patentfamilien für UMTS und LTE vorsieht. Die Z1 Computer Inc. legte der Klägerin mit Schreiben vom 6. Juni 2016 Rechnung und hinterlegte beim Amtsgericht München eine Sicherheit in Höhe von € ..., wobei die nach dem Gegenangebot auf der Grundlage der Rechnungslegung errechneten Lizenzgebühren USD ... betragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen zwischen den Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Klägerin trägt vor,

sie sei aktivlegitimiert, weil sie das Klagepatent niemals an die Sharp. Corporation übertragen hatte. Dies sei nur bei UMTS-Patenten der Fall gewesen.

Die nach dem LTE-Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen machten von der patentgemäßen Lehre des Anspruchs 7 des Klagepatents unmittelbar Gebrauch, da die Befolgung der Vorgaben des LTE-Standards für die Zusammenstellung der Daten für den UL-SCH zu einer Benutzung der patentgemäßen Lehre führe. Insbesondere seien Mittel im Sinne der Merkmalsgruppe d vorhanden. Es sei nicht erforderlich, dass die zu übertragende Datengruppe *a priori* in zwei Teile aufgeteilt werde und jeder dieser Teile immer mindestens ein Element enthalte. Unerheblich sei auch, dass bei dem Standard in dem Fall, in dem die PBR

eines der logischen Kanäle auf Unendlich gesetzt sei und für diesen Kanal Datenpakete anstünden, die den gesamten Platz des Transportblocks ausfüllten, nur die Daten dieses priorisierten Kanals übertragen würden, da dies ein Sonderfall sei und die Mobilstation auch im Normalfall funktionieren müsse, nämlich dann, wenn von der Radio Ressource Control (RRC) der höheren Schichten kein Kanal mit einer PBR von Unendlich belegt sei. Auch Merkmal f sei verwirklicht. Verzögerungskriterium sei der für jeden logischen Kanal j geführte Parameter B_j. Da dieser Parameter in jedem Verfahrensschritt neu berechnet werde, indem er für jedes Übertragungszeitintervall um den Faktor PBR x TTI erhöht und, falls Datenpakete dieses Kanals übertragen werden, um die Gesamtgröße der übertragenen MAC-SDUs aus diesem Kanal verringert werde, ließe sich am Parameter B_j ablesen, ob die Datenpakete des jeweiligen Kanals j verzögert oder „on schedule" seien. Da zunächst die Daten aus Kanälen mit $B_j > 0$ und innerhalb dieser Gruppe nach ihrer Priorität und danach – sofern noch Kapazität übrig sei – die Daten aus den übrigen Kanälen nach deren Priorität unabhängig vom B_j-Wert für die Zusammenstellung des Transportblocks ausgewählt würden, seien nicht nur zwei Auswahlregeln gegeben, sondern es richte sich die Anzahl der nach der ersten und der zweiten Regel ausgewählten Daten und damit die Größe der beiden Teile des Transportblocks daher auch nach einem Verzögerungskriterium. Eine aktive Anpassung der Größe der beiden Teile des Datengruppe sei nicht erforderlich. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei bei den angegriffenen Ausführungsformen auch ein patentgemäßer Warteschlangenspeicher vorhanden.

Das Klagepatent werde sich im Nichtigkeitsverfahren auch als rechtsbeständig erweisen.

Schließlich greife der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Einwand nicht durch, da sie die Beklagte insbesondere vor Klageerhebung in ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres FRAND-Angebots informiert und damit alle Obliegenheiten, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Huawei./.ZTE formuliert habe, bereits vor Klageerhebung erfüllt habe. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr je Einheit aus, die überdies unter Bezugnahme auf den Wert und die Größe des Patentportfolios erläutert worden sei, sowie die Mitteilung eines Vergleichs mit dem Samsung-Portfolio sowie der Verweis auf die bestehenden Lizenznehmer L1, L2, L3, L4 und L5 (Anlage K4c) und ein Gutachten aus dem L1-Verfahren. Jedenfalls sei ausreichend, dass die Klägerin die von der Beklagten vermissten Erläuterungen in ihrer Replik gemacht habe. Zu näheren Erläuterungen sei sie gegenüber der im Grundsatz lizenzunwilligen Beklagten ohnedies nicht verpflichtet gewesen.

Die Klägerin **b e a n t r a g t**,

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

   Multiplexgerät[e] zum Multiplexen von Datenpaketen mit verschiedenen zugeordneten Prioritäten, mit: Mitteln zum Empfangen von Datenpaketen; Mitteln zum Bedienen eines Warteschlangenspeichers für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen; Mitteln zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete, wobei durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher nach einer ersten Regel ein erster Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird; Mitteln zum Übertragen der Gruppe,

   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   wenn das Multiplexgerät weiterhin Mittel umfasst zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher erfahrenen Verzögerung.

   – Patentanspruch 7 –

2. Die Beklagte wird verurteilt,

   der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben a und b unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die in Unterziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 12. September 2009 begangen hat, und zwar unter Angabe

   a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

   b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten und seit dem 12. September 2009 gegangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt.

1) die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 12. September 2009 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 60 2005 016 008.6 (deutscher Teil des EP1 815 647 b1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

2) die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer 1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise:

das Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens gegen das Klagepatent auszusetzen.

Die Beklagte trägt vor,
die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert. Sie müsse mit Nichtwissen bestreiten, dass das Klagepatent nicht doch an die Sharp Corporation übertragen worden sei.

Die Einhaltung der Vorgaben des Standards führten nicht dazu, dass die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machten. Die Merkmalsgruppe d sei nicht verwirklicht. Der LTE-Standard schreibe nicht vor, dass die zur Übertragung vorgesehenen Datenpakete zwingend nach zwei Regeln zusammengestellt würden. Setze die RRC die PBR eines Kanals auf Unendlich, würden nur die Daten dieses Kanals und keine anderen übertragen. Nach dem Standard sei damit gerade nicht ausgeschlossen, dass einzelne Datenpakete „verhungern," was der Verwirklichung der Lehre des Klagepatents indes entgegenstehe. Eine zweite Regel komme auch dann nicht zur Anwendung, wenn bereits alle Ressourcen des Transportblocks durch die erste Regel befüllt worden seien. Auch Merkmal f sei nicht verwirklicht. Merkmal f fordere zum einen die aktive Anpassung eines ersten und zweiten Teils der Datengruppe durch eine vorherige Festlegung der Größe der jeweiligen Teilbereiche durch die Mobilstation mit einer anschließenden Befüllung der beiden Bereiche anhand der ersten und der zweiten Regel gem. Merkmalsgruppe d. Dies sei beim Standard nicht der Fall. Schritt 3 komme dort nur zur Anwendung, wenn noch Kapazitäten vorhanden seien. Selbst dann würden aber keine Bereich aktiv festgelegt, sondern eine Aufteilung würde sich rein passiv durch das Befüllung ergeben, was für eine Verwirklichung von Merkmal f nicht ausreiche. Zum anderen liege überdies keine Anpassung gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen

Warteschlangenspeicher erfahrenen Verzögerung im Sinne des Merkmal f vor. Der Parameter B_i stelle weder einen Indikator für eine anspruchsgemäße zeitliche Verzögerung der Daten noch ein anspruchsgemäßes Verzögerungskriterium dar. Es handle sich um eine bloße Datenmenge. Ungeachtet dessen könne er bereits deshalb keine Anhaltspunkte für eine zeitliche Verzögerung von Datenpaketen liefern, weil er auch dann größer Null sein könne, wenn überhaupt keine verzögerten Daten vorlägen. Für die Größe des ersten Teilbereichs des Transportblocks sei nicht die Verzögerung von Datenpaketen, sondern die Anzahl der Datenpakete in den Warteschlangenspeichern mit einem B_i -Wert größer Null relevant, so dass weder die Größe des ersten noch des zweiten Teils verzögerungsorientiert angepasst werde. Eine verzögerungsorientierte Zuteilung im Schritt 3 finde nicht statt, die Zuteilung erfolge strikt nach Priorität. Erst Recht finde keine Anpassung der beiden Teile des Transportblocks anhand der zeitlichen Verzögerung eines jeden Warteschlangenspeichers statt. Wenn die Größe des ersten und zweiten Teils von der PBR abhänge, wie die Klägerin behaupte, erfolge deren Anpassung auch deshalb nicht anhand einer zeitliche Verzögerung, sondern anhand eines Parameters, der von den höheren Schichten vorgegeben werde. Die Klägerin habe die Verwirklichung des Merkmals f letztlich nicht schlüssig dargelegt.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin habe insbesondere vor Klageerhebung trotz Aufforderung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche.

Zudem werde sich das Klagepatent nicht gegenüber dem Nichtigkeitsangriff behaupten können. Das dort eingeführte Dokument WW4, welches im Zusammenhang mit dem Dokument WW3 als einheitliche Offenbarung zu werten sei, nehme die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich vorweg, lege aber die Erfindung jedenfalls nahe.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist nur in Teilen begründet.

Die auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Vernichtung gerichteten Anträge waren abzuweisen, da die Klägerin an der Durchsetzung der Ansprüche aus kartellrechtlichen Gründen gehindert ist.

Da die angegriffenen Ausführungsformen indes von der Lehre des geltend gemachten Hauptanspruchs 7 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch machen, war die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Schadensersatzverpflichtung festzustellen.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick die erhobene Nichtigkeitsklage war nicht angezeigt.

0. Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Ausweislich des Registers (Anlage KD1b) ist die Klägerin Anmelderin und Inhaberin des Klagepatents. Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, dennoch nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Eine Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt. (BGH, Urteil vom 7. Mai 2013 – X ZR 69/11, BGHZ 197, 196, Rn. 55 ff. – Fräsverfahren).

   Ein Inhaberwechsel zur S. Corporation ist nicht eingetragen. Ferner ist auch aus der von den Parteien in Bezug genommenen, im Parallelverfahren vorgelegten Anlage K11 eine Rückübertragung des Klagepatents auf die Klägerin von Seiten der S. Corporation nicht ersichtlich, was die Registerlage bestätigt. Anders als in den Parallelerfahren hat die Klägerin im hiesigen Verfahren gerade nicht einen solchen Übertragungsvorgang behauptet und offengelegt. Vor diesen Hintergrund vermag das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen, dass die Registerlage der materiellen Rechtslage entspricht die Indizwirkung des Registereintrages nicht zu überwinden.

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Zusammenstellen von Datenpaketen, etwa in Mobilfunknetzwerken.

   Zum Hintergrund erläutert das Klagepatent, dass in Kommunikationssystemen Datenpakete mit unterschiedlichen Prioritäten zusammengestellt werden müssten, wofür der Begriff „multiplexen“ verwendet wird. Anhand des Beispiels des aus verschiedenen

Protokollschichten zusammengesetzten UMTS-Standards erläutert das Klagepatent, dass dort an der MAC-Schicht (Medium Access Control) Datenpakete, nämlich MAC-d Protokolldaten (Protocol Data Units = PDUs), für die Übertragung zu verbesserten (enhanced) MAC-e PDUs zusammengefasst würden. Dabei würden die Datenpakete nach der ihnen zugewiesenen Priorität zusammengestellt. Bei einer begrenzten Kapazität der für die Übertragung zusammengestellten Datengruppe, der Mac-e PDUs, könne eine reine Zusammenstellung nach der Priorität dazu führen, dass Datenpakete mit einer geringeren Priorität nicht zum Zuge kommen und „verhungern." Eine ausschließliche Orientierung an der Priorität würde nicht immer zu einer optimalen Befüllung der MAC-e PDUs führen und sei zu unflexibel, um alle „Quality of Service"- Anforderungen für PDUs, wie Anforderungen an die Verzögerung und die Übertragungsraten dieser Daten, zu erfüllen. Als im Stand der Technik bekannte Lösungsmöglichkeit erwähnt das Klagepatent die US-Anmeldung No. 2004/0042420, bei der der Multiplexer, also die Einheit, die die Zusammenstellung der Daten für die Übertragung vornehme, segmentierte Datenpakete mit niedriger Priorität jeweils nach einer Übertragung von n Datenpaketen mit einer hohen Priorität übertrage.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein flexibles und effizientes Multiplexen von Datenpaketen zu ermöglichen. Soweit es eine Vorrichtung betrifft, schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung nach Anspruch 7 vor, der sich wie folgt übersetzen und gliedern lässt:

a Multiplexgerät (300) zum Multiplexen von Datenpaketen mit verschiedenen zugeordneten Prioritäten, mit:

b Mitteln (10) zum Empfangen von Datenpaketen;

c Mitteln (30, 40) zum Bedienen eines Warteschlangespeichers (50) für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen;

d Mitteln (60, 80) zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete, wobei

d1 durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer ersten Regel ein erster Teil (90) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und

d2 durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil (95) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird;

e Mitteln (100) zum Übertragen der Gruppe;

gekennzeichnet durch,

f. Mittel (110) zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils (90,95) gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher (50) relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher (50) erfahrenen Verzögerung.

II. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 7 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies steht aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung der Parteien für sämtliche Anspruchsmerkmale mit Ausnahme der Merkmalsgruppe d und des Merkmals f außer Streit. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch die streitigen Merkmale.

Maßgeblich für die Auslegung eines Patents ist zunächst der Inhalt und damit der Wortlaut und Sinngehalt des jeweiligen Patentanspruchs, Beschreibung und Zeichnungen sind ergänzend heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1, S. 1, 2 EPÜ). Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentschrift herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 – *Schneidmesser I* BGH GRUR 1999, 909 – *Spannschraube*). Die Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH, GRUR 2005, 754 – *werkstoffeinstückig*). Ausführungsbeispiele sowie darauf bezogene Beschreibungsteile schränken einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausführungsformen ein.

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe sind die streitigen Merkmale durch die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Merkmalsgruppe d sieht Mittel (60, 80) zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete vor, wobei (Untermerkmal d 1) durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer ersten Regel ein erster Teil (90) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und (Untermerkmal d 2) durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil (95) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird.

   a) Mit der Zweckbestimmung „Mittel zum“ legt die Merkmalsgruppe d bestimmte Fähigkeiten fest, die ein patentgemäßes Multiplexgerät haben muss. Demnach muss es dazu in der Lage sein, eine Gruppe der Datenpakete zusammenzusetzen.

Dabei muss das Zusammensetzen so möglich sein, dass durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren Warteschlangenspeicher nach einer ersten Regel ein erster Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt und durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren Warteschlangenspeicher nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird. Hieraus folgt, dass ein patentgemäßer Multiplexer nach zwei unterschiedlichen Regeln befüllen können muss. Ob er daneben auch noch dazu in der Lage ist, nach einer weiteren Regel zu befüllen, hierzu enthält das Klagepatent keine Festlegung und schließt dies insbesondere auch nicht aus. Soweit der Anspruch eine Datengruppe erwähnt, handelt es sich nicht um einen irgendwie gearteten physischen Bestandteil des Multiplexgeräts wie etwa einen besonderen physikalischen Speicher, denn das Multiplexgerät muss nur Mittel zum Zusammensetzen einer Datengruppe im Sinne der Merkmalsgruppe d enthalten. Der Anspruch spricht auch nur allgemein von Datengruppe, ohne auf die Art und Weise der technischen Realisierung einzugehen. Die Datengruppe stellt daher lediglich eine Menge von Daten dar, ohne dass das Klagepatent eine bestimmte Form der physischen Abspeicherung vorschreiben würde. Dementsprechend sind auch der erste und der zweite Teil einer Datengruppe nicht so zu verstehen, dass sich die Merkmalsgruppe d etwa auf einen bestimmten physikalischen Speicher, der in zwei Teile geteilt ist, bezieht. Auch insofern handelt es sich lediglich um abstrakte Teilmengen der Datengruppe. Dabei ist nicht erforderlich, dass eine Datengruppe stets aus zwei nicht leeren Teilmengen bestehen muss, die nach zwei unterschiedlichen Regeln befüllt werden, mithin stets zwei Regeln zur Anwendung kommen müssten. Der Patentanspruch legt schon nicht fest, dass eine Datengruppe stets und ausnahmslos aus zwei solchen Teilen bestehen müsste. Abgesehen davon fordert Merkmalsgruppe d lediglich eine bestimmte Eignung des Multiplexgerätes, nämlich Datenpakete nach der Merkmalsgruppe d zusammenstellen zu können. Nicht gefordert ist darüber hinaus, dass der Multiplexer diese Eignung stets nutzen müsste, indem er stets und ausschließlich zwei Regeln anwendet und damit zweigeteilte Datengruppen zusammenstellt, in denen sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Regel ausgewählte Datenpakete enthalten sind. Es genügt, dass er solche Datengruppen zusammenstellen kann. Die Regeln, die der Multiplexer bei der Auswahlentscheidung anwenden können muss, müssen demnach nicht so ausgestaltet sein, dass sie stets zu einer Befüllung der Datengruppe mit sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Regel ausgewählten Daten führen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Abschnitt [0008] der Patentbeschreibung. Es spricht schon vieles dafür, dass sich diese Ausführungen allein auf den Verfahrensanspruch 1 beziehen, denn in Abschnitt [0007] wird einleitend der Verfahrensanspruch als ein Aspekt der Erfindung genannt, während erst im Anschluss an die nachfolgenden Abschnitte, nämlich in Abschnitt [0013], der Vorrichtungsanspruch als ein zweiter Aspekt der Erfindung genannt wird. Aber selbst wenn man Abschnitt [0008] als allgemeine Beschreibung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ansehen wollte, könnte hieraus nicht gefolgert werden, dass nur eine Eignung, stets und ausschließlich zweigeteilte Datenpakete unter ausnahmsloser Anwendung von zwei Regeln zusammenzustellen, patentgemäß wäre. Zwar heißt es dort, dass die Erfindung Flexibilität für eine angemessene Handhabung von Prioritäten, garantierten Bitraten und „Verhungern von Daten"-Szenarien dadurch bereitstelle, dass ein Datenpaket, das groß genug für die Unterbringung mehrere kleiner Datenpakete sei, in zumindest zwei Teile geteilt wird und dass ermöglicht wird, unterschiedliche Multiplex-Regeln für verschiedene Teile zu benutzen. Gleichzeitig heißt es jedoch auch, dass auf diese Weise die Übersendung einer Kombination von Datenpaketen mit unterschiedlicher Priorität ermöglicht werden kann *(„may be transmitted")*. Hieraus ergibt sich, dass nicht jede zu übertragende Datengruppe in zwei Teile geteilt sein muss, sondern auch eine Datengruppe mit Daten nur einer Priorität zulässig ist. Hinzu kommt, dass es sich bei Anspruch 7 um einen Vorrichtungsanspruch handelt, der in Merkmalgruppe d – wie bereits ausgeführt – lediglich eine Eignung vorsieht, nicht aber ausschließt, dass die Vorrichtung auch nach anderen Vorgaben verfahren kann. Mithin genügt es für die Verwirklichung der Merkmalsgruppe d, wenn der Multiplexer dann, wenn zwei unterschiedliche Regeln zur Anwendung kommen sollen, dazu in der Lage ist, eine zu übertragende Datengruppe zu befüllen, indem für einen ersten Teil nach der ersten und für einen zweiten Teil nach der zweiten Regel ausgewählt wird.

Nichts anderes ergibt sich auch aus Abschnitt [0015] der Klagepatentschrift, in dem es heißt, dass der Ausgangsspeicher einen ersten und einen zweiten Teil umfasst und beide jeweils mindestens ein Datenpaket unterbringen können, zumal es sich um ein Ausführungsbeispiel handelt und Anspruch 7 abstrakt von einer Datengruppe spricht und sich nicht auf einen Speicher festlegt.

Ebenso wenig ist erforderlich, dass von vornherein eine bestimmte Größe für die Datengruppe und für ihren ersten und zweiten Teil festgelegt wird. Auch insoweit enthält der Patentanspruch keine Vorgaben. Hinzu kommt wiederum, dass Anspruch 7 lediglich eine bestimmte Eignung fordert, nämlich einen ersten Teil der

Datengruppe nach einer ersten und einen zweiten Teil nach einer zweiten Regel zu befüllen, ohne dass vorgegeben würde, dass der Multiplexer immer so verfahren müsste.

Auch aus dem Umstand, dass das Klagepatent ein „Verhungern" von Datenpaketen zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen gewählt hat, folgt nicht, dass der Multiplexer stets bei jedem Befüllen der zu übertragenden Datengruppe zwei Regeln anwenden müsste. Wiederum gilt, dass Merkmalsgruppe d lediglich fordert, dass er geeignet ist, zwei Regeln bei der Auswahl anzuwenden und damit einen ersten und zweiten Teil der Datengruppe zu befüllen. Dass ein Verhungern von Daten ausgeschlossen sein müsste, hat im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden.

Soweit in den Merkmalen d1 und d2 das Befüllen der Datengruppe mit Daten aus mindestens einem Warteschlangenspeicher nach einer ersten bzw. zweiten Regel angesprochen ist, bedeutet dies nicht, dass beide Regeln nur solche Daten beträfen, die bereits bei einer Übertragung nicht zum Zuge gekommen sind und daher auf ihre Übertragung „warten" würden. Mit Warteschlangenspeicher in den Merkmalen d1 und d2 wird lediglich die Fähigkeit der Speicher zum Ausdruck gebracht, dass diese Speicher auch dazu in der Lage sein müssen, nicht zum Zuge gekommene Datenpakete zu speichern, bis diese für die Übertragung an der Reihe sind. Irgendwelche Einschränkungen mit Blick auf den Inhalt der beiden Regeln, etwa dass es sich um Regeln handeln müsste, die jeweils nur verzögerte Daten betreffen, sind damit nicht verbunden. Eine solche Einschränkung widerspräche auch Unteranspruch 8, der gerade vorsieht, dass nach der ersten Regel nur Datenpakete mit der höchsten Priorität ausgewählt werden. Das Klagepatent schließt es mithin nicht aus, dass ein Teil der übertragenen Datenpakete solche sind, die nicht verzögert sind.

b) Vor diesem Hintergrund verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen die Merkmalsgruppe d, weil sie ein Befüllen mit zwei unterschiedlichen Regeln durchführen können.

Nach Abschnitt 5.4.3.1 des Standards übermittelt der RRC für jeden logischen Kanal eine Priorität *(Priority)*, wobei ein ansteigender Wert ein geringeres Prioritätslevel anzeigt, eine *prioritizedBitRate*, die eine priorisierte Bitrate (PBR) festlegt, und eine *bucketSizeDuration*, die die Dauer der Größe der Übertragungseinheit (BSD) festlegt. Ferner erhält die Mobilstation für jeden logischen Kanal j einen Parameter B_j, der bei der Einrichtung des logischen Kanals mit dem Wert Null initialisiert wird und wie im Tatbestand dargestellt berechnet

wird. Anknüpfend an diesen Parameter sieht das Verfahren in Abschnitt 5.4.3.1 des Standards bei der Zuteilung der Übertragungskapazitäten des Transportblocks an die einzelnen logischen Kanäle bei einer neuen Übertragung vor, dass zunächst alle logischen Kanäle mit $B_j > 0$ in absteigender Prioritätsreihenfolge zum Zuge kommen. Erst wenn danach noch Platz in dem zu übersenden Transportblock ist, kommen im Zuge des dritten Schritts die übrigen logischen Kanäle in streng absteigender Prioritätsreihenfolge zum Zuge.

Damit sieht der Standard anhand des Unterscheidungskriteriums $B_j > 0$ zwei verschiedene Regeln für das Befüllen des Transportblocks mit Daten der logischen Kanäle vor. Der Schritt 1 stellt die erste Regel dar, nach der ein erster Teil der zu übertragenden Datengruppe befüllt wird, nämlich mit Daten aus logischen Kanälen mit $B_j > 0$. Der Schritt 3 ist die zweite Regel, nach der allein nach Priorität ein zweiter Teil befüllt wird. Damit sorgt dieses Verfahren dafür, dass nicht allein hochpriorisierte Daten übersandt werden, indem solche Daten mit niedriger Priorität, die indes einen positiven B_j haben, weil sie beim letzten Übertragungsvorgang nicht berücksichtigt wurden, nun vorrangig vor den Daten des logischen Kanals mit der höchsten Priorität, der jedoch beim letzten Übertragungsvorgang berücksichtigt wurde, übersandt werden.

Nach der oben dargelegten Auslegung des Patentanspruchs ist es unerheblich, dass es möglich ist, dass durch ein Setzen der PBR auf Unendlich für einen logischen Kanal mit einer zur Übertragung anstehenden Menge an Daten, die die Kapazität der zu übertragenden Datengruppe übersteigt, bewirkt wird, dass nur diese höchstpriorisierten Daten in die Datengruppe gelangen, und dass durch unbegrenztes Wiederholen dieser Einstellung sogar gänzlich verhindert werden kann, dass andere Daten mit niedriger Priorität übertragen werden, denn es genügt, dass nach dem Standard auch Fälle möglich sind, in denen beide Auswahlschritte zur Anwendung kommen und die LTE-fähigen Mobilstationen dann auch diese Auswahl umsetzen können. Wie ausgeführt fordert das Klagepatent nicht, dass die Datengruppe stets und ausschließlich nach zwei unterschiedlichen Regeln zusammengesetzt wird. Aus dem gleichen Grund ist es unschädlich, dass es auf der Grundlage des Standards denkbar ist, dass so viele Daten in einem oder mehreren logischen Kanälen mit $B_j > 0$ zur Übertragung anstehen, dass in der Datengruppe kein Platz mehr für die Datenpakete nach Schritt 3 des Standardabschnitts 5.4.3.1 ist und daher alle zu übersendenden Datenpakete nach nur einer Regel zusammengestellt sind. Patentrechtlich ohne Bedeutung ist auch, ob mit den Auswahlregeln des Standards sicher verhindert wird, dass einige Datenpakete „verhungern". Denn dass ein solches Verhungern

unter allen Umständen ausgeschlossen sein müsste, hat jedenfalls keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden.

3. Auch Merkmal f des Klagepatents ist durch die nach dem LTE-Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht. Merkmal f sieht Mittel (110) zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils (90,95) [erg: der zu übertragenden Datengruppe] gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher (50) relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher (50) erfahrenen Verzögerung vor.

   a) Merkmal f sieht zunächst ein Verzögerungskriterium für den betreffende Warteschlangenspeicher vor. Ein merkmalsgemäßes Verzögerungskriterium muss sich demnach auf den Warteschlangenspeicher, der wiederum Datenpakete mit gleicher Priorität enthält, und nicht auf die Daten selbst beziehen. Welchen weiteren konkreten Inhalt das Verzögerungskriterium hat, insbesondere auf welche Weise es eine Verzögerung zum Ausdruck bringt, lässt das Merkmal offen. Insbesondere sind anspruchsgemäße Verzögerungskriterien nicht allein solche Größen, die die Dimension bzw. Maßeinheit Zeit haben. Eine entsprechende Einschränkung lässt sich dem maßgeblichen Wortlaut des Patentanspruchs nicht entnehmen. Zwar wird in Abschnitt [0012] der Patentbeschreibung eine Anpassung gemäß einer durch die Daten erfahrenen Verzögerung in der Warteschlange relativ zu einem Verzögerungskriterium u.a. einer Anpassung gemäß der Datenmenge in den Warteschlangenspeichern gegenübergestellt. Hieraus lässt sich jedoch nicht mit der notwendigen Sicherheit entnehmen, dass die Patentbeschreibung eine Datenmenge nicht als Verzögerungskriterium auffassen würde. Denn auch die Feststellung der Existenz einer Verzögerung durch das Vorhandensein einer verzögerten Datenmenge kann als Verzögerungskriterium angesprochen werden.

   Ferner stellt Merkmal f auf eine Verzögerung *(delay)* ab, die die Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu dem Verzögerungskriterium erfahren haben. Mit einer Verzögerung der Daten ist gemeint, dass die betreffenden Daten bei einer Übersendung nicht zum Zuge gekommen sind. Auch insoweit lässt der Anspruch offen, wie im Einzelnen technisch festgestellt wird, dass eine Verzögerung bei den Daten vorliegt, solange die Verzögerung relativ zu einem Verzögerungskriterium für den Warteschlangenspeicher der betroffenen Daten ist. Gemäß dieser Verzögerung der Daten wird die Größe des in Merkmalsgruppe d genannten ersten und zweiten Teils der zu übertragenden Datengruppe angepasst. Eine Anpassung in diesem Sinne ist nicht nur dann gegeben, wenn eine bereits von vornherein vorgegebene Größe aktiv angepasst wird, sondern

auch dann, wenn infolge einer Verzögerung Regeln zur Anwendung kommen, die sich auf die Größe des ersten und zweiten Teils der Datengruppe auswirken. Dem Wortlaut lässt sich das Erfordernis einer aktiven Anpassung einer vorher vorgegebenen Größe nicht entnehmen. Vielmehr sieht der Vorrichtungsanspruch 7 allein vor, dass Mittel vorhanden sein müssen, die eine entsprechende Anpassung bewirken. Auf welche Weise dies geschieht, lässt der Anspruch offen. Insbesondere können daher auch die zur Anwendung berufenen Auswahlregeln Mittel sein, die zu einer Anpassung der Größe führen. Die Beklagte hat auch keine Stelle in der Patentbeschreibung aufgezeigt, die ein anderes Verständnis rechtfertigen würde. Dem Klagepatent lässt sich ferner nicht entnehmen, dass der Umfang der Verzögerung in den Warteschlangenspeichern die Art und Weise der Aufteilung, insbesondere die Größe des ersten und zweiten Teils beeinflussen müsste. Es genügt vielmehr, wenn lediglich daran angeknüpft wird, dass eine Verzögerung vorliegt, und dieser Umstand die Aufteilung beeinflusst.

Da auch Merkmal f lediglich Mittel vorsieht, die in der Lage sind, wie in Merkmal f vorgesehen zu verfahren, aber nach seinem Wortlaut nicht ausschließt, dass das Multiplexgerät auch auf andere Weise verfahren kann, oder vorgibt, dass das Multiplexgerät immer wie in Merkmal f niedergelegt verfahren müsste, führt es aus dem Anspruch nicht heraus, wenn ein Multiplexgerät nicht immer die Prozedur nach Merkmal f durchführt, sondern etwa Daten auch unabhängig von einer Verzögerung priorisiert, etwa weil aus dem betreffenden Warteschlangenspeicher bei der letzten Übersendung keine Daten mangels anstehender Daten übersendet wurden.

b) Nach der vorstehenden Maßgabe machen die angegriffenen Ausführungsformen von Merkmal f Gebrauch.

Der Parameter B_j stellt ein merkmalsgemäßes Verzögerungskriterium dar. Wie ausgeführt muss sich ein solches Verzögerungskriterium auf den betreffenden Warteschlangenspeicher beziehen. Dies ist bei dem Parameter B_j nach dem Standard der Fall. Nach Abschnitt 5.4.3.1 ist dieser Parameter dem jeweiligen logischen Kanal j zugeordnet, für den eine festgelegte Priorität besteht. Für jedes Übertragungsintervall wird der Parameter um den Faktor PBR x TTI erhöht und nach Schritt 1 um die Menge der nach Schritt 1 übertragenen Daten reduziert. Er ist damit ein Maß für eine Verzögerung des Kanals selbst und gibt an, ob der Kanal bei der letzten Versendung voll zum Zuge kam. Ein positiver Wert kann dabei verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann er theoretisch darauf beruhen, dass in einem Zeitintervall eine kleinere Datenmenge übertragen wurde,

als das Produkt PBR x TTI, also die priorisierte Bitrate mal der Zeiteinheit, als Datenmenge angibt, sei es, weil in die zu übertragende Datengruppe weniger Daten dieses Kanals eingestellt wurden, als zur Übertragung anstehen, oder weil die in dem Kanal vorhandene Datenmenge kleiner als die Summe aus dem alten Wert für B_j und dem Produkt PBR x TTI ist. Überdies findet die Erhöhung um den Faktor PBR x TTI unabhängig davon statt, ob für diesen Kanal überhaupt Datenpakete zur Übertragung anstehen. Auch aus diesem Grund kann ein logischer Kanal einen Wert $B_j > 0$ aufweisen, obwohl für diesen Kanal keine verzögerten Datenpakete vorhanden sind, die im vorangegangenen Übertragungsintervall nicht zum Zuge gekommen sind. Ein positiver Wert von B_j für einen Kanal bringt daher zum Ausdruck, dass der Kanal – aus welchen Gründen auch immer – bei den letzten Übertragungsvorgängen nicht im Umfang des Produktes PBR x TTI zum Zuge kam und daher insoweit verzögert ist. Mithin handelt es sich bei dem Parameter B_j um ein Verzögerungskriterium für den Kanal. Es kann daher offen bleiben, ob eine Anknüpfung an eine Datenmenge aufgrund einer bewussten Auswahlentscheidung der Patentinhaberin nach den Grundsätzen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2011, 701 ff. – Okklusionsvorrichtung nicht patentgemäß wäre, da der Parameter B_j nicht, jedenfalls nicht unmittelbar an eine Datenmenge, sondern an eine Verzögerung des Kanals anknüpft. Aber selbst wenn man das Verzögerungskriterium als Verzögerungskriterium für die Daten selbst, das für den jeweiligen Kanal festgelegt ist, verstehen wollte, würde es aus dem Patentanspruch nicht hinausführen, dass B_j seiner Dimension nach eine Datenmenge darstellt. Wie dargelegt, muss das Verzögerungskriterium keine zeitliche Größe in dem Sinne sein, dass es die Dimension/Maßeinheit „Zeit" hat.

Sind indes Daten eines bestimmten logischen Kanals bei einer vorangegangenen Übersendung nicht zum Zug gekommen, handelt es sich um verzögerte Daten im Sinne des Klagepatents. In diesem Fall stellt der Parameter B_j mit einem positiven Wert zugleich einen Hinweis dar, dass diese Daten verzögert sind. Es handelt sich damit um Daten, die relativ zum Verzögerungskriterium für den betreffende Warteschlangenspeicher verzögert sind und die daher nach Schritt 1 behandelt werden. Dass nach dem Standard nach dem Vorstehenden ein Kanal mit $B_j > 0$ auch ohne verzögerte Daten existieren kann und dann nach Schritt 1 bevorzugt behandelt wird, mithin ein positiver Wert keine hinreichende Bedingung für die Existenz verzögerter Daten ist, führt nach den obigen Ausführungen nicht aus dem Patentanspruch hinaus, da dieser lediglich bestimmte Fähigkeiten fordert, aber

nicht vorschreibt, dass das Multiplexgerät mit Datenpaketen ausschließlich wie in den Merkmalen d und f beschrieben verfährt.

Nicht von den Parteien erörtert wurde, ob es Konstellationen geben kann, in denen verzögerte Daten vorliegen und in denen B_j gleichwohl nicht positiv ist, weil er auch negative Werte annehmen kann, so dass die Erhöhung um den Faktor PBR x TTI unter Umständen vielleicht keinen positiven Wert ergibt, obwohl verzögerte Daten vorliegen, so dass ein positiver Wert keine notwendige Bedingung für die Existenz verzögerter Daten sein könnte. Aus den im Rahmen der Auslegung erörterten Gründen kann dies jedoch dahinstehen. Denn wiederum gilt, dass der Patentanspruch nicht vorschreibt, dass die Vorrichtung ausschließlich nach der Merkmalsgruppe d verfährt.

Sind logische Kanäle mit verzögerten Datenpaketen, die bei der vorangegangenen Übertragung nicht zum Zug gekommen sind, vorhanden, haben diese nach dem Standard jedenfalls in bestimmten Konstellationen einen positiven Wert B_j und werden daher nach Schritt 1 behandelt. Damit haben vorhandene verzögerte Daten unmittelbaren Einfluss auf die Größe der Teilmenge des Transportblocks, die nach Schritt 1 behandelt wird. Dass es – wie erörtert – auch Konstellationen gibt, in denen $B_j > 0$ ist, obwohl keine verzögerten Daten vorhanden sind, oder B_j trotz verzögerter Daten evtl. sogar nicht positiv sein mag und damit die Größe des ersten Teils der zu übertragenden Datengruppe insoweit nicht, jedenfalls nicht allein durch die Verzögerung von Daten, bestimmt wird, ist unerheblich. Denn nach dem Standard sind auch Konstellationen möglich, in denen bei positiven B_j-Werten verzögerte Daten vorliegen. Auch in diesem Fall muss eine Mobilstation nach den Regeln in Abschnitt 5.4.3.1 arbeiten können, was wie dargelegt für die Verwirklichung des Merkmals f ausreicht. Der Patentanspruch verbietet es nicht, dass das Verzögerungskriterium in anderen Konstellationen kein Indikator für die Verzögerung von Daten ist. Wie ebenfalls bereits ausgeführt, fordert der Patentanspruch auch nicht, dass die Größe der Teile der zu übertragenden Datengruppe stets und ausschließlich nach dem Kriterium in Merkmal f bemessen wird. Für die Verwirklichung von Merkmal f reicht es vielmehr aus, wenn das Multiplexgerät eine Größenanpassung wie in Merkmal f vorgesehen bewirkt, sofern verzögerte Daten vorliegen.

Aus den gleichen Gründen ist es auch ohne Bedeutung, dass in bestimmten Konstellationen, etwa wenn die Anzahl der Daten in Kanälen mit positiven B_j-Werten die Kapazität der Datengruppe überschreitet, die Anpassung der Größe der beiden Teile nicht anhand der Verzögerung eines jeden

Warteschlangenspeichers stattfindet, solange es Konstellationen gibt, in denen aufgrund der gewählten Parameter die positiven B_j-Werten mit der Existenz von verzögerten Daten gleichgesetzt werden können und die genannten zwei Regeln zur Anwendung kommen. Wie bereits ausgeführt, ist es auch nicht erforderlich, dass der Umfang der Verzögerung die Aufteilung beeinflusst.

Unerheblich für die Verwirklichung von Merkmal f ist ferner, dass in die Berechnung von B_j mit den Parametern PBR und TTI Werte einfließen, die von den höheren Schichten vorgegeben werden, und hierdurch das Vorzeichen von B_j mit bestimmt wird. Dieser Umstand ändert nichts daran, dass der Parameter B_j jedenfalls in bestimmten Konstellationen ein Indikator für eine Verzögerung darstellt.

Aus den oben genannten Gründen ist es für die Verwirklichung von Merkmal f auch unschädlich, dass im Standard keine bestimmte Größe einer ersten und zweiten Teilmenge des Transportblocks vorgegeben und diese Größe dann vor jeder Übertragung aktiv anhand der Verzögerung nach Merkmal f angepasst wird. Es genügt vielmehr, dass die Anpassung Folge der für diesen Fall aufgerufenen Auswahlregeln ist.

Schließlich ist auch unerheblich, dass der Standard nicht auf Warteschlangenspeicher für jede unterschiedliche Priorität abstellt, sondern auf logische Kanäle abhebt, denen bestimmte Prioritäten zugewiesen sind. Denn die Daten aus einem logischen Kanal sind denklogisch abgespeichert und können als zusammengehörige Daten eines Kanals abgerufen werden, so dass die Speicherorte als patentgemäße Warteschlangenspeicher anzusehen sind.

III. Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die zu dem Klagepatente gestellten Anträge, soweit sie auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet sind. Diesen Ansprüchen stehen kartellrechtliche Gesichtspunkte nicht entgegen (vgl. Huawei Technologies/ZTE: EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

1. Die Beklagte ist der Klägerin aufgrund der vorliegenden Verletzung der Klagepatente zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet. Die Klägerin kann den Schadensersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten

naturgemäß unbekannt sind, die Beklagte hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Arbeitsaufwand Auskunft geben kann, ist die Beklagte gem. § 140 b PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet. Diese Auskunft hat sich für die Zeit seit Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents zzgl. Kenntnisnahmefrist von einem Monat auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden.

2. Zudem war wie beantragt festzustellen, dass die Beklagte in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Schadensersatz verpflichtet ist.

   Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie den Antrag auf Zahlung von Schadensersatz und Entschädigung nicht beziffern. Da aber die Beklagte Schadensersatzansprüche der Klägerin in Abrede stellt, hat die Klägerin – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der 30jährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

   Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird.

IV. Hingegen war die Klage abzuweisen, soweit die Klägerin überdies von der Beklagten Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie die Vernichtung patentverletzender Produkte begehrt. Denn insoweit stehen einer gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe entgegen.

1. Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache Huawei Technologies/ZTE im Urteil vom 29. Januar 2016 - 7 O 66/15

(veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht. Dass der Gerichtshof diesen Gesichtspunkt, den der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen angesprochen hat, in seiner Urteilsbegründung nicht ausdrücklich erwähnt, bedeutet nach Ansicht der Kammer entgegen den Darlegungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschl. v. 31.5.2016 - 6 U 55/16, MittdtschPatAnw 2016, 321) nicht, dass das vom Gerichtshof für Recht erkannte System nicht praxisgerecht sein soll.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass

der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich

um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, sei Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat dabei vielmehr die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.

Der Verletzer muss auf dieses, auf konkret darzulegenden Tatsachen fußende Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen

Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

2. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen.

   a) Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, im Detail einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben.

   b) Denn die Klägerin hat vorliegend ihre Obliegenheit nicht erfüllt, gegenüber der Beklagten transparent zu machen, aufgrund welcher Tatsachen sie den von ihr im Lizenzvertragsangebot geforderten Lizenzsatz von US$ 1,-- pro Stück für FRAND hält - bzw. warum dieser in der Diktion des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Rahmen des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums FRAND ist. Sie hat sich vielmehr darauf beschränkt, in ihrem Angebot pauschal zu behaupten, dass die angemessene Lizenz US$ 1,-- bzw. 0,75 US$ pro Stück sei. Insoweit ist nach

Auffassung der Kammer die bloße Angabe der Multiplikatoren nicht annährend ausreichend, um die Vorgaben der Entscheidung des Gerichtshofs zu erfüllen. Auch der pauschale Verweis auf weitere Lizenznehmer ohne nähere Erläuterung der Lizenzbedingungen sowie der gleichfalls pauschale Verweis auf das Portfolio von Samsung sowie ein nicht zugänglich gemachtes Sachverständigengutachten aus dem Sony-Verfahren haben die Beklagte nicht in die Lage versetzt, valide zu prüfen, ob das Angebot der Klägerin FRAND ist und nicht hinreichend plausibel gemacht, warum die Klägerin meint, der Auffassung sein zu dürfen, die von ihr geforderten Konditionen entsprächen FRAND.

c) Soweit die Klägerin darauf hinweist, die Kammer würde sich in Widerspruch zur Spruchpraxis ihrer Schwesterkammer setzen, ist die Kammer unter Beachtung des zwischenzeitlich ergangenen und zuvor zitierten Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe der Auffassung, dass eine bloße Angabe der Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde liegen, nicht ausreichend sind. Denn anhand dieser Parameter ist es dem vermeintlichen Verletzer nicht möglich zu beurteilen, ob das Angebot - entweder im Sinne einer Evidenzkontrolle wie sie die Kammer vertritt oder im Sinne einer objektiven Bestimmung unter Berücksichtigung eines auch vom Oberlandesgericht zugestandenen Entscheidungsspielraums - FRAND ist und gegebenenfalls ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu machen, da es ihm, wie der Gerichtshof ausführt, regelmäßig gerade an den hierzu nötigen Informationen über den Lizenzmarkt fehlt, über die der SEP-Inhaber verfügt.

d) Soweit die Klägerin entsprechende Erläuterungen erstmals in der Replik gemacht hat, sind diese nach Klageerhebung erfolgt und damit nicht mehr geeignet, die vom Europäischen Gerichtshof verfolgte Intention zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Erhebung einer auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten Klage führen zu können. Insoweit sind die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs nach Auffassung der Kammer vor dem Hintergrund der Intention, die der Gerichtshof mit seinem Pflichtenprogramm verfolgt, zu verstehen, dass nicht nur vor Klageerhebung auf die Art und Weise der vorgeworfenen Patentverletzung hingewiesen werden soll. Sondern dieses zeitliche Erfordernis bezieht sich gleichfalls auf die Angabe, auf welche Art und Weise sich die Lizenzgebühr im Angebot des SEP-Inhabers berechnet, also aufgrund welcher Tatsachen die konkret geforderte Gegenleistung für die Lizenzierung fair, vernünftig und nicht diskriminierend sei soll. Denn nur wenn auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr vor Klageerhebung substantiiert wurde, kann sich der angebliche Verletzer, ohne dem Druck einer

bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden, ob er gewillt ist, die so transparent gemachten Bedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und Lizenz zu nehmen. Soweit in einem jüngst ergangenen Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Mai 2016 (Az.: I - 15 U 36/16) das Gericht erwägt, ob es in allen Fällen erforderlich ist, dass die vom Gerichtshof aufgestellten Obliegenheiten, hier insbesondere die Verpflichtung zur Erläuterung der Gebührenberechnung, vor Klageerhebung zu erfüllen sind und ob dies gegebenenfalls als zu formaljuristisches Verständnis der Entscheidung abzulehnen ist, hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest. Denn selbst wenn es prozessual möglich sein sollte, dass die Klägerin, die ihre Obliegenheiten bislang nicht vor Klageerhebung erfüllt hat, dies nachholt, die zunächst erhobene Klage zurücknimmt und dann unter Beachtung der Obliegenheiten erneut erhebt, ist zu sehen, dass in diesem Fall in der Zeit zwischen der Rücknahme der zunächst erhobenen Klage und erneuter Erhebung der Klage Zeit für Verhandlungen bleibt, in denen die Verhandlungen ohne den unmittelbaren Druck eines gerichtlichen Verfahrens geführt werden können. Denn selbst wenn der SEP-Inhaber entsprechend im ersten Verfahren die zunächst unterlassene Erläuterung nachholt, so wird er dem vermeintlichen Verletzer vor erneuter Klageerhebung eine gewisse Zeit zuzugestehen haben, in der der Beklagte die Argumente prüft, die der SEP-Inhaber zur Untermauerung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzhöhe sowie der Frage, ob die angesonnene Lizenzgebühr FRAND entspricht, vorgebracht hat. Würde man es uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholen kann, so würde nach Ansicht der Kammer der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshof, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und zu diesem Zeitpunkt über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das angesonnene Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt. Die Kammer sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung" sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen.

e) Die Klägerin war auch vorliegend nicht etwa von dieser Obliegenheit entbunden, weil sich die Beklagte als lizenzunwillig gezeigt hätte. Denn selbst wenn im Zuge der Verhandlungen zwischen den Parteien vereinzelt eine Zahlung von Lizenzgebühren durch die Beklagte in einzelnen Aussagen abgelehnt worden sein sollte, so hat die Beklagte sich nach Auffassung der Kammer nicht grundsätzlich

lizenzunwillig gezeigt, da sie in einer Vielzahl von Treffen einen möglichen Lizenzvertrag diskutiert hat. Zudem ist aus Sicht der Kammer zu berücksichtigen, dass die Beklagte bzw. deren Muttergesellschaft – wenngleich erst nach Klageerhebung – ein Gegenangebot unterbreitet und einen namhaften Betrag hinterlegt hat, der nahezu das Dreifache des Betrages abdeckt, der sich auf der Grundlage der gleichfalls geleisteten Rechnungslegung und des Gegenangebots ergibt. Zwar liegen diese Umstände nach Klageerhebung, indes wertet die Kammer dieses Verhalten als Indiz auch für die grundsätzliche Lizenzwilligkeit der Beklagten bzw. der Muttergesellschaft jedenfalls in einem solchen Maße, dass die nähere Erläuterung der kaufmännischen Bedingungen, hier insbesondere der Höhe der verlangten Lizenzgebühr nicht obsolet gewesen wäre. Denn das Gesamtverhalten der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft lassen nicht den Schluss zu, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung besteht darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die angesonnenen Angebote FRAND entsprechen.

V. Der Rechtsstreit war nicht bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen. Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

   Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von der Beklagtenseite glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende, mithin überwiegende Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten *Grabinski/Zülch* in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 107).

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen. Von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass

das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, ist die Kammer nicht überzeugt.

a) Die Darlegungen der Beklagten zu einer Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltung TW4/WW3 und WW4 können die Kammer nicht von einer hinreichenden Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage überzeugen. Dabei kann dahinstehen, ob die Dokumente nicht zu berücksichtigende unfertige Entwicklungen, die die beanspruchte Lehre noch nicht als ausführbare Anweisung enthalten, darstellen, wie die Klägerin meint.

aa) Die Entgegenhaltungen befassen sich mit dem Festlegen und Zuweisen von Übertragungsraten („*Rate Scheduling*") auf einem bestimmten Kanal von Mobilstation zu Basisstation. Dabei sprechen sie zwei Vorgehensweisen an, nämlich ein „*per UE basis rate scheduling*" und ein „*per priority queue basis rate scheduling*".

bb) Der in der Schrift gelehrten Vorgehensweise „*per UE basis rate scheduling*" vermag die Kammer nicht die Offenbarung von zwei Regeln entnehmen. Die Darstellungen in der Entgegenhaltung sind recht abstrakt. Insbesondere wird nicht konkret aufgezeigt, nach welcher bzw. ggf. welchen konkreten Regeln der sog. TFC die MAC-e PDU bestückt.

Auch mit Blick auf das „per priority queue basis rate scheduling", das die Beklagte ins Zentrum ihrer Argumentation stellt, hat die Beklagte nicht hinreichend aufgezeigt, dass das Multiplexgerät der Mobilstation nach zwei verschiedenen Regeln zu arbeiten in der Lage ist. Dem Vortrag der Klägerin, dass der Multiplexer strikt nach vorgegebener Datenrate auswähle, ist die Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten. Wie sich den Bullet Points über der Fig. 2 entnehmen ist, gibt die Basisstation (Node B) für jede Prioritätswarteschlange eine Datenrate vor und der TFC-Auswahl-Algorithmus wählt die Transportformatkombination (TFC) basierend allein auf der von der Basisstation gewährten Datenrate für jede Prioritätswarteschlange. Auf welche konkrete Art und Weise die Datenraten bestimmt werden, insbesondere ob der Bestimmung zwei Regeln zugrunde liegen, wird in der Entgegenhaltung jedenfalls für die nicht sachkundig besetzte Kammer nicht hinreichend deutlich.

b) Soweit sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung auf den Vortrag der Beklagten im gemeinsam verhandelten Verfahren 7 O 30/16 zu der US-Schrift ´420 bezogen und insoweit Beiziehung der Akten beantragt hat, genügt ein solcher Vortrag schon in formaler Hinsicht nicht, um die Kammer zur Aussetzung des

Verfahrens zu veranlassen. Denn ein Beklagter, der eine Aussetzung des Rechtsstreits mit der Begründung erreichen will, das Klagepatent werde sich nicht als rechtsbeständig erweisen, muss der nicht fachmännisch besetzten Kammer darlegen, warum sein vor dem Bundespatentgericht geführter Angriff gegen den Rechtsbestand mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird. Dafür genügt eine pauschale Bezugnahme auf den angeblichen Vortrag eines anderen Beklagten in einem anderen Verfahren nicht aus. Zudem geht die Bezugnahme vorliegend schon deshalb ins Leere, weil die Beklagte im Verfahren 7 O 30/16 keinen Angriff gegen den Rechtsbestand des Klagepatents geführt hat und sich allein im Rahmen der Auslegung der Patentansprüche mit der US-Schrift befasst.

VI. Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 S. 1, 709 S. 1 und 2 ZPO.

Verkündet am 16.12.2016

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle